

1500606-57.2021.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... e traziam consigo, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 49 pedras de crack, com peso bruto de 23,02 gramas; 17 microtubos de cocaína, com peso bruto de 27,91 gramas; e 45 unidades de maconha, com peso bruto de 45,90 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito; sua prisão em flagrante foi convertida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Centro - CEP 11750-000, Fone: (13) 3455-3629,

Peruíbe-SP - E-mail: peruibe2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500606-57.2021.8.26.0441 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Data da Audiência:

20/01/2022 às 16:15h

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TOMAS CARLOS DA MOTA

Vistos.

TOMAS CARLOS DA MOTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de julho de 2021, por volta das 15h32min, na Rua Vinte e seis, nº 520, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, juntamente com pessoa não identificada, envolvendo na traficância o adolescente Matheus Henrique da Silva Machado, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 49 pedras de crack, com peso bruto de 23,02 gramas; 17 microtubos de cocaína, com peso bruto de 27,91 gramas; e 45 unidades de maconha, com peso bruto de 45,90 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito; sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 65/66).

O acusado foi regularmente citado e notificado (fls. 157), e apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 83/87), recebida a denúncia (fls. 92/93).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a absolvição do acusado, assim como a defesa.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Eis a prova produzida:

O policial militar ROBERTO PINHEIRO relatou em Juízo que O local é conhecido dos meios policiais, palco de vários flagrantes. Em diligência no local, ingressaram na

viela e visualizaram três pessoas. O réu Tomas, ao perceber que se tratava da polícia, gritou "Molhou". Correu e deteve o menor de idade que estava com a sacola. Todos tentaram se evadir. Com o adolescente, encontraram as drogas variadas. Já conhecia o réu, pois ele estava sempre na campana. Ele estava próximo da sacola, mas não o viu mexendo. Ele confessou que estava de campana. O campana nem participa da venda. A função dele era só avisar, caso a polícia apareça.

O policial militar ANDERSON CARLOS LOMENZO BUONO descreveu em Juízo que O réu é conhecido da polícia. É usuário de crack. Já o pegaram várias vezes. Dessa vez o pegaram, pois ele gritou e correu. Ele confessou que estava na campana para satisfazer seu vício. Ele ganhava R\$ 50,00 e trocava por "pedra". Havia também um adolescente na "sacola", que correu e foi detido com uma sacola cheia de drogas. Estavam em viatura descaracterizada. O réu estava com cabelo cumprido e mais magro. Ele já conhece o veículo descaracterizado. Quando o réu viu, gritou "molhou" e correu. Foi atrás dele. Ele não correu muito e foi detido. Confessou informalmente que estava na campana. Não deu tempo de ver nenhum ato de venda. Viram a droga. Eles estavam mexendo na sacola de entorpecentes na hora. Com o réu, nenhuma droga foi encontrada pois a função dele era de campana. A sacola estava no chão. Depois da prisão do réu, o tráfico continua funcionando no local.

O réu, ouvido em Juízo, disse que, no dia em que foi preso, não estava trabalhando de campana. Tinha ido comprar drogas. Não gritou nada, nem correu. Ficou parado. Ficou com uma policial feminina, enquanto os dois policiais homens correram atrás das duas pessoas que estavam vendendo a droga. Não tem nada contra os policiais. Já os viu lá e eles diziam "sai fora noia". Não sabe a razão deles terem lhe conduzido para a delegacia.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar a condenação.

Nesse ponto, observo que, em juízo, não restou esclarecida a conduta do réu. Os policiais ouvidos informaram não ter visto o réu em nenhum ato de efetiva mercancia. Disseram que o viram apenas como "campana", tendo anunciado a presença policial, proferindo o termo "molhou". Essa conduta, a rigor, poderia ser eventualmente enquadrada na figura típica do artigo 37 da Lei de Drogas, que trata da figura do "olheiro". Fato é, contudo, que mesmo quanto ao referido delito, persiste dúvida, já que o réu, ouvido em juízo, alegou que estava no local apenas para comprar drogas e sustentar seu vício, o que encontra respaldo na versão dos próprios policiais, que afirmaram conhecê-lo como usuário de drogas.

O prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será

privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 - e-book).

Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

Ademais, pleiteando o Ministério Público, em alegações finais, a absolvição do réu, não há alternativa ao juiz a não ser o decreto absolutório, em virtude da não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição, por afronta ao sistema acusatório (art. 129, inc. I da CRFB).

No sistema acusatório, há completa separação entre as funções de acusar e julgar; o Juiz deve estar rigidamente separado das partes, com equidistância, em observância ao princípio da imparcialidade.

O pedido de absolvição veiculado pelo representante do Ministério Público, titular da ação penal, faz desaparecer a acusação. Em outras palavras, não subsiste a pretensão acusatória.

E, não havendo mais acusação por parte do titular da ação penal, eventual sentença condenatória resultaria no acúmulo das funções de acusar e punir por parte do magistrado.

Portanto, "viola o sistema acusatório constitucional a regra prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o juiz condenar ainda que o Ministério Público peça absolvição. Também representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão acusatória"

(LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal, 16ª Edição. São Paulo. Saraiva. 2019. P. 917).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação

penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia.

Dada a solução de mérito adotada, faculto ao réu recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 20 de janeiro de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Juiz Substituto